

1500935-23.2021.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Gustavo de Campos Machado

Comarca: Caçapava

Foro: Foro de Caçapava

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/02/2022

... confessaram informalmente a prática do tráfico aos policiais. Não sabe o motivo pelo qual os policiais militares disseram que Rafael também confessou a prática do tráfico. Esclareceu que essa foi a primeira vez que traficou, pois sempre trabalhou.

A versão dos acusados contrasta veementemente com a narrativa dos policiais militares.

Com efeito, o policial militar WALACE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Vara Criminal

Rua Marquês do Herval, 269, Caçapava-SP - cep 12281-510

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500935-23.2021.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500935-23.2021.8.26.0618

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2178494/2021 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 18831765 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 1455/21/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 1455/2021 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2178494 - Delegacia de Polícia de Caçapava

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WASHINGTON LUIZ MOREIRA CRISPIM e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS.

WASHINGTON LUIZ MOREIRA CRISPIM, PAULO RICARDO GONÇALVES DOS SANTOS e RAFAEL MOREIRA DIONÍSIO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei n.º 11.343/06 c/c o artigo 61,

inciso II, alínea j, do Código Penal, porque, no dia 02 de julho de 2021, nesta cidade e comarca de Caçapava, previamente ajustados e com unidade de desígnios, traziam consigo e guardavam, para fins de comércio e entrega a consumo de terceiros, drogas, consistentes em 78 (setenta e oito) porções de Cannabis sativa L. (maconha) e 88 (oitenta e oito) porções de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 17/18 e laudo de constatação provisória a fls. 20/23, sendo o crime praticado com o emprego de arma de fogo com a numeração suprimida.

WASHINGTON LUIZ MOREIRA CRISPIM e RAFAEL MOREIRA DIONÍSIO foram notificados (fls. 145) e apresentaram defesa prévia (fls. 142/143).

PAULO RICARDO GONÇALVES DOS SANTOS foi notificado (fls. 144) e apresentou defesa prévia (fls. 153/154).

A denúncia foi recebida em 29 de novembro de 2021 (fls. 167/169) e os acusados foram citados pessoalmente.

Durante a instrução, realizada virtualmente em razão da pandemia do novo coronavírus, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, bem como foram os réus interrogados. Houve debates orais.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal merece ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se provada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 1/2), Boletim de Ocorrência (fls. 14/16), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 17/18), Laudo de Constatação Provisória (fls. 20/23), Fotografia (fls. 100), Exame Químico-Toxicológico (fls. 120/122), Laudo Pericial da Arma (fls. 129/131) e pela prova oral coligida.

A autoria desponta nítida e indubitosa.

Em interrogatório judicial, WASHINGTON LUIZ MOREIRA CRISPIM declarou que tem 21 anos, é solteiro, tem dois filhos, trabalhava na Casa de Ração antes de ser preso, possui passagem na adolescência por roubo e tráfico e, depois de atingida a maioridade, teve problema com desacato. Quanto aos fatos, confessou que ele e Paulo estavam traficando, porém, seu irmão Rafael não estava envolvido com a traficância. Disse que Rafael apareceu no local apenas para comprar cocaína. Asseverou que Rafael foi ao ponto comprar mais cocaína para usar, mas acabou ficando no local cheirando cocaína com Paulo. Admitiu que Rafael estava armado no dia dos fatos. Declarou que o rádio comunicador estava com o interrogando e não com Rafael. Acredita que os policiais cometeram um engano ao dizer que o rádio comunicador estava com seu irmão Rafael. Quanto à confissão informal, contou que apenas ele e Paulo confessaram o tráfico. Reafirmou que Rafael estava apenas cheirando com Paulo e não tem nada a ver com o tráfico. Está arrependido do que fez.

Ao ser interrogado em juízo, RAFAEL MOREIRA DIONÍSIO disse que tem 19 anos, é solteiro, não tem filhos, ajudava seu pai, não teve passagem na Vara da Infância, nunca foi processado criminalmente, usa cocaína. Quanto aos fatos, admitiu que estava na posse de um revólver, porém, não estava participando do tráfico em conluio com os demais réus. Contou que comprou o revólver, pois passou a ser ameaçado pelo ex-namorado de sua atual namorada. Disse que pagou pelo revólver a quantia de R\$1.000,00, esclarecendo que conseguiu o dinheiro ajudando seu pai como pedreiro. Afirmou que, no dia, foi comprar cocaína, mas não estava com dinheiro, apenas com o revólver. Indagado como iria comprar drogas sem dinheiro, respondeu que estava apenas com R\$10,00. Quanto ao rádio, disse que ele estava com os meninos e não tem nada a ver com o tráfico. Não é verdade que confessou informalmente a prática do tráfico aos policiais militares.

Durante interrogatório judicial, PAULO RICARDO GONÇALVES DOS SANTOS declarou que tem 20 anos, é solteiro, sua mulher está grávida, trabalhava de pintor, nunca foi processado na infância, tampouco depois de atingida a maioridade. Quanto aos fatos, confessou que estava no tráfico, pois estava passando necessidade e havia perdido o emprego. Ponderou que está arrependido do que fez; é verdade que o interrogando e Washington estavam traficando. Disse, porém, que Rafael não estava traficando; pelo que sabe, Rafael estava na casa da tia e subiu para comprar uma porção de pó, razão pela qual o interrogando o convidou para usar drogas. Rafael estava com

R\$10,00. Pediu para Rafael segurar o rádio e foi nesse momento que os policiais chegaram. Somente o interrogando e Washington confessaram informalmente a prática do tráfico aos policiais. Não sabe o motivo pelo qual os policiais militares disseram que Rafael também confessou a prática do tráfico. Esclareceu que essa foi a primeira vez que traficou, pois sempre trabalhou.

A versão dos acusados contrasta veementemente com a narrativa dos policiais militares.

Com efeito, o policial militar WALACE FERREIRA CORREA, sob o crivo do contraditório, disse que, no dia, receberam denúncia 190 de que estaria havendo o tráfico na Rua 4 do Bairro Pinus Dois e que um dos envolvidos estaria armado. Com o auxílio da equipe de Força Tática, esta adentrou na Rua 4 e sua equipe ingressou na Rua 3, vindo a se deparar com a pessoa dos réus. Com Rafael localizaram uma arma, municiada e raspada, além de um rádio comunicador. Os outros dois indivíduos portavam cada um uma sacola com drogas e dinheiro. Os três réus confessaram de pronto e informalmente a prática do delito. Não havia mais ninguém além dos réus no momento da abordagem e eles estavam portando uma sacola com drogas. Salvo engano, eles têm antecedentes criminais, mas não se recorda quem.

A corroborar, o agente militar FLÁVIO DIAS DE MORAES, em juízo, confirmou que, na data dos fatos, estavam fazendo patrulhamento de rotina quando viram três indivíduos no final da rua em um local onde costuma haver a venda de drogas perto de um sofá, razão pela resolveram abordá-los, oportunidade em que acharam 78 buchas de maconha e R\$85,00 com Washington; com Rafael localizaram um revólver municiado com numeração raspada e um rádio e com Paulo apreenderam 38 papелotes de cocaína, mais R\$136,00 em dinheiro. Os réus confessaram informalmente a prática de tráfico. Além do mais, o local da abordagem é conhecido como biqueira de drogas. Segundo os réus, a arma seria para a defesa dos réus. Não viu mais ninguém no local da abordagem além dos acusados, reafirmando que a arma e as drogas foram achadas em poder dos réus. Os acusados eram conhecidos e já foram abordados algumas vezes rotineiramente, mas nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Os réus não ameaçaram os policiais no momento da abordagem. Não se recorda se foi achada alguma anotação, mas os três acusados confessaram informalmente a prática do tráfico. Pois bem!

Em que pese a negativa de RAFAEL e a tentativa dos demais acusados de atenuarem sua responsabilidade criminal, não há razões para se duvidar da lisura da ação policial, contra a qual não foi comprovada qualquer causa de suspeição ou inidoneidade, não sendo crível que as testemunhas WALACE FERREIRA CORREA e FLÁVIO DIAS DE MORAES forjariam evidências em desfavor de RAFAEL.

Com efeito, os agentes estatais foram firmes e harmônicos em dizer que receberam informações de que no local havia um indivíduo armado, razão pela qual foram até o endereço informado e verificaram a presença dos réus. Em revista pessoal, com WASHINGTON encontraram 78 porções de maconha e a quantia de R\$ 85,00 em dinheiro; com PAULO RICARDO apreenderam 88 porções de cocaína e R\$ 136,00 em dinheiro e com RAFAEL localizaram um revólver, marca Rossi, calibre 22, com a numeração suprimida, municiado, além de um rádio comunicador.

Disseram os policiais militares WALACE e FLÁVIO, outrossim, que os três acusados, ao serem questionados no momento da abordagem, admitiram informalmente e em tom uníssono que estavam comercializando drogas no local.

A esse respeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à validade dos testemunhos prestados por agentes policiais que tenham participado das diligências que culminaram com a captura do investigado ou com sua prisão em flagrante, tanto o mais quando não derruída a prova por outros elementos probatórios, como no caso em apreço.

Nesse sentido: “o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar – tal como ocorre com as

demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos" (STF - HC nº 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

É evidente que RAFAEL estava conluiado com PAULO RICARDO e com seu irmão WASHINGTON na venda espúria de drogas, apesar destes dois últimos terem buscado atenuar sua responsabilidade criminal.

Ora, RAFAEL admitiu informalmente a prática do tráfico aos agentes estatais e foi surpreendido na posse de uma arma de fogo e de um rádio comunicador normalmente utilizado pelos traficantes para o fim de avisar a aproximação da polícia.

Afora isso, RAFAEL não comprovou sua condição de usuário de drogas, tampouco a existência das alegadas ameaças sofridas que justifiquem a posse da arma de fogo em local conhecido como ponto de venda de drogas.

Adicionalmente, RAFAEL não possuía renda lícita comprovada suficiente para adquirir uma arma por R\$1.000,00, bem como saciar seu vício por cocaína, como alegou em seu interrogatório judicial, sendo evidente que faz do tráfico seu meio de vida e subsistência em conluio com os demais acusados.

De todo modo, eventual condição de usuário de RAFAEL não afasta, por si só, a de traficante, já que é de sabença geral que muitos usuários se envolvem com o tráfico à vista da necessidade de sustentar o próprio vício, recebendo porções de droga como pagamento pela mercancia ilícita praticada.

Por fim, os réus WASHINGTON e PAULO apresentaram versões contraditórias acerca da posse do rádio comunicador. A esse respeito, WASHINGTON disse que o rádio comunicador foi apreendido em seu poder, enquanto PAULO afirmou que era ele quem portava o rádio e o repassou a RAFAEL minutos antes da abordagem policial.

De tudo isso se extrai, portanto, que os três réus estavam conluiados e que as drogas apreendidas a todos pertenciam e que se destinavam ao comércio nefasto.

Além do mais, a quantidade e variedade dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, a existência de denúncia dando conta da presença de um indivíduo armado no local, a apreensão de numerário, arma de fogo e de um rádio comunicador em local conhecido como ponto de tráfico, associada à confissão informal dos réus aos agentes militares, confirmam o dolo de traficar dos acusados.

Para Fernando de Almeida Pedroso, "em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo" (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96).

A propósito, sobre o tema, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (RT 584/347. Nesse mesmo sentido: RT 714/357, RJTJSP 63/316, 70/371 e 97/512).

Por fim, os elementos de prova produzidos em juízo deram conta de que a arma apreendida em poder de RAFAEL se destinava ao tráfico, tratando-se de instrumento de proteção e intimidação voltada à prática da atividade ilícita. Logo, não é o caso de desclassificação, afigurando-se correta a capitulação jurídica contida na denúncia por se tratar evidentemente de tráfico armado.

Nesse sentido, é o entendimento esposado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARMA APREENDIDA NO CONTEXTO DO TRÁFICO. ABSORÇÃO. CRIME MEIO. INCIDÊNCIA DO ART. 40, IV, DA LEI 11.343/06. NEGATIVA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROCESSOS EM ANDAMENTO. ILEGALIDADE. 1. "É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para

assegurar o sucesso da mercancia ilícita. Nesse caso, trata-se de crime meio para se atingir o crime fim que é o tráfico de drogas, exige-se o nexu finalístico entre as condutas de portar ou possuir arma de fogo e aquelas relativas ao tráfico (HC n. 181.400/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 17/4/2012, DJe 29/6/2012). 2. Se a abordagem do réu, a quem era atribuída a distribuição de drogas em conhecido ponto de tráfico, se deu "utilizando, para tanto, um veículo Fiat Linea Prata", onde foi encontrado, "sobre o banco do motorista, um revólver cromado, municiado com 05 cartuchos, além de parte das drogas descritas no auto de apreensão, que estavam em um dos bolsos do casaco do réu", enquadra-se tal conduta na norma contida no art. 40, IV, da Lei 11.434/06, segundo a qual, a pena relativa ao delito do art. 33 é aumentada de 1/6 a 2/3 se a infração tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva, e não como delito autônomo. 3. A existência de ações penais em curso e de registros de atos infracionais, por si só, não constituem fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. 4. Considerando-se o quantum de pena aplicado e a não relevante quantidade de entorpecentes (43,4 gramas de cocaína), fixa-se o regime inicial aberto, devendo a pena privativa de liberdade ser substituída por penas restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33 e 44 do Código Penal. 5. Agravo Regimental provido. Paciente incurso no art. 33, caput e § 4º, c/c o art. 40, VI, da Lei 11.343/06. Condenação (re) fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 dias-multa. Substituição da pena de reclusão por penas restritivas de direitos, a ser fixadas pelo Juízo da Execução. (AgRg no HC 591.478/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021, g.n.). Os denunciados praticaram o crime em ocasião de calamidade pública no Estado de São Paulo, em razão da Pandemia do Novo Coronavírus.

Desse modo, comprovadas a materialidade e autoria de WASHINGTON LUIZ MOREIRA CRISPIM, PAULO RICARDO GONÇALVES DOS SANTOS e RAFAEL MOREIRA DIONISIO, é de rigor sua condenação como incursos no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei n.º 11.343/06 c/c o artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal. Passo, com fulcro nos artigos 42 da Lei n.º 11.343/2006 e artigos 59 e 68 do Código Penal, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, considerando a quantidade e natureza das drogas, sobretudo da cocaína, com alto poder destrutivo, o que denota maior reprovabilidade da conduta, majoro a pena base para os três réus em 1/5, resultando no total provisório de 6 anos de reclusão, além de 600 dias-multa.

A propósito: "O art. 42 da Lei nº 11.343/06 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base, quanto na determinação do grau de redução da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da nova Lei de Tóxicos" (STJ, 5ª T., HC 225.575/ES, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJe. de 05-06-12, grifei).

Na segunda fase, presente a agravante do artigo 61, II, "j", do Código Penal, já que o crime foi praticado pelos acusados em ocasião de calamidade pública provocada pela pandemia do novo coronavírus, bem como presente a atenuante da menoridade relativa (artigo 65, I e III, "d" do CP).

Não se pode negar que os réus se valeram de uma situação pandêmica e dramática vivenciada pela coletividade, notoriamente reconhecida como calamidade, para o fim de obter renda fácil, passando a se dedicar ao tráfico, em prejuízo ao bem jurídico tutelado pela própria norma, qual seja, a saúde e bem-estar da coletividade. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão, tendo em vista que a confissão feita pelos réus em juízo foi apenas parcial, já que tentaram isentar RAFAEL de responsabilidade e afastar a existência do tráfico armado.

Nesse sentido o posicionamento da doutrina:

"A confissão, para valer como meio de prova, precisa ser voluntária, ou seja, livremente praticada, sem qualquer coação. Entretanto, para servir de atenuante, deve ser ainda espontânea, vale dizer, sinceramente desejada, de acordo com o

íntimo do agente (...). Não é possível que o réu se beneficie de uma circunstância legal para amenizar sua pena se houver agido sem qualquer espontaneidade, apenas para locupletar-se de algum benefício legal". (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 5ª edição, Ed. RT, p. 358, nota 86).

No mesmo sentido o posicionamento da jurisprudência:

"A confissão só pode ser reconhecida como atenuante obrigatória quando se dá de forma completa, a fim de se prestigiar a sinceridade do infrator, pois, em hipótese contrária, inexistente verdade total da dinâmica da ocorrência penal" (TACRSP, RJDTACRIM 31/84).

"Em se tratando da atenuante da confissão, o agente que, buscando minimizar sua conduta, compromete a verdade processual, não pode reclamar a obtenção do valor legal, pois, além do requisito da espontaneidade, não se admite, para efeito de atenuação de penas, confissão pela metade" (TACRSP, RJDTACRIM 33/56).

Desse modo, realizo a compensação entre tais circunstâncias (menoridade relativa e calamidade pública), mantendo as penas fixadas na fase anterior.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena do artigo 40, IV da Lei 11.343/2006, pois o crime de tráfico foi praticado pelos réus com emprego de arma. Assim, considerando que a arma de fogo estava municiada com duas munições intactas e com número de série suprimido, situação que implica maior reprovabilidade na conduta, majoro as penas acima em 1/3, resultando em 08 anos de reclusão, além de 740 dias-multa.

Na derradeira etapa, no tocante a WASHINGTON, incabível a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois, conquanto primário, sem antecedentes criminais e de inexistirem indícios de que esteja envolvido com organização criminosa (fls. 192/193), é inegável sua dedicação reiterada às atividades criminosas diante de seus antecedentes infracionais por tráfico de drogas e roubo, conforme admitiu em seu interrogatório judicial e ilustrado a fls. 36.

Muito embora não seja possível sopesar tal circunstância para considerá-lo reincidente ou portador de maus antecedentes, conforme entendimento reiterado do C. Superior Tribunal de Justiça, não há nenhum óbice para levá-la em consideração como indicativo de dedicação do réu WASHINGTON às atividades criminosas, a reforçar a necessidade de afastamento do privilégio.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. Como é consabido, para a incidência da minorante especial prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é necessário o preenchimento dos requisitos legais previstos no dispositivo, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação às atividades criminosas e não integração à organização criminosa. 3. A existência de atos infracionais praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.560.667/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 23/10/2017 grifo nosso).

HABEAS CORPUS Nº 460.141 - SP (2018/0180069-2) RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. MODO FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a

atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). Concluído pela instância antecedente, com fulcro na quantidade e na variedade dos entorpecentes apreendidos - 30 eppendorfs de cocaína (44,1g) e 71 invólucros de maconha (1,190kg) -, assim como nos anteriores registros da prática de atos infracionais análogos aos delitos de tráfico e de roubo, que o paciente se dedica a atividade criminosa, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes. 5. Embora o paciente seja primário e pena tenha sido estabelecida em 5 anos de reclusão, o regime inicial fechado é o adequado para a reprovação do delito, tendo em vista a expressiva quantidade de droga apreendida, nos exatos termos dos arts. 42 da Lei de Drogas c/c o art. 59 e 33 do Código Penal. 6. In casu, a dedução do período de prisão cautelar não tem o condão de abrandar o regime prisional estabelecido, diante da presença de fundamento válido para o modo mais gravoso - a expressiva quantidade de droga. 7. É inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pela falta do atendimento do requisito objetivo, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 8. Habeas corpus não conhecido (HC Nº 460.141-SP - STJ - RELATOR MINISTRO RIBEIRO DANTAS - 04/09/2018).

No tocante à PAULO RICARDO e RAFAEL, ausentes causas de aumento de pena. Todavia, os réus fazem jus à diminuição de 2/3 das penas com fulcro no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, o que resulta no total de 02 anos e 08 meses de reclusão, além de 266 dias-multa, pois, além de primários e sem antecedentes criminais (fls. 189/190 e fls. 191), não são membros de organização criminosa.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, uma vez que não há nos autos elementos que comprovem a capacidade econômica dos réus.

Excepcionalmente, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena aos réus PAULO RICARDO e RAFAEL, tendo em vista as circunstâncias judiciais favoráveis, sua primariedade (fls. 189/191). O tempo de prisão preventiva (desde 02/06/2021) e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Não obstante este magistrado tenha reiteradamente decidido em casos idênticos de maneira diversa, ao adotar regime fechado no tráfico privilegiado, curvo-me ao recente posicionamento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus n.º 596.603 - SP (2020/0170612-1), de relatoria do MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, em observância aos princípios da hierarquia jurisdicional e da segurança jurídica, fixando regime mais brando.

Em atenção ao balizado pela C. Superior Instância, no tocante a PAULO RICARDO e RAFAEL, reputo preenchidos os requisitos previstos pelo artigo 44, do Código Penal, razão pela qual substituo a pena privativa por prestação de serviços à comunidade, que serão especificados pelo juízo da execução, e a prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo em favor de entidades assistenciais, recaiando, preferencialmente, em favor daquelas voltadas a reabilitação de dependentes químicos.

Ainda, quanto à possibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos, cabe observar o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal: "A Turma concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus para possibilitar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao paciente condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, desde que cumpridos os demais requisitos exigidos pela lei. Salientou-se que, uma vez verificada essa possibilidade, não há impedimento para que se fixe o regime inicialmente aberto para o cumprimento da pena, já que o objetivo da conversão é evitar o encarceramento. Frisou-se, ainda, que esse posicionamento busca apenas adequar a fixação do regime ao entendimento do STF, aplicando-se especificamente aos delitos de tráfico e apenas em razão da declaração de inconstitucionalidade das expressões da lei que vedavam a substituição. Precedentes citados do STF: HC 97.256-RS, DJe 15/12/2010; HC 104.423-AL, DJe 7/10/2010; HC 102.678-MG, DJe 23/4/2010, e HC 105.779-SP, DJe 21/2/2011". HC 196.199-RS, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em

5/4/2011.

Em relação ao réu WASHINGTON, à vista da quantidade de pena aplicada, superior a quatro anos de reclusão, bem como em face da insuficiência da medida, inviável a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, ex vi do disposto no artigo 44, I e III do Código Penal.

No sentido de que eventual substituição da pena corporal por restritivas de direitos não se revela suficiente para punir e prevenir condutas que tais, confira-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES EM ASSOCIAÇÃO.

CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE PROVA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR OUTRA RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DIVERSIDADE IMPOSSIBILIDADE. 1. A caracterização do crime de associação permanente para o tráfico de entorpecentes, enquanto requisita o reexame do conjunto da prova é inadequado ao âmbito angusto do habeas corpus. 2. A consideração do magistrado sentenciante na individualização da pena de que o paciente 'pertence a uma hierarquia superior no tráfico de entorpecentes, coordenando os outros dois acusados na distribuição da droga na Região', para além de lhe serem desfavoráveis as circunstâncias e conseqüências do crime, não são circunstâncias estranhas ao elenco do artigo 59 do Código Penal, sendo bastante à exasperação da pena-base acima do mínimo legal. 3. A substituição da pena privativa de liberdade pela sanção restritiva de direitos, prevista no artigo 44 do Código Penal, enquanto resposta penal em natureza, está subordinada, inarredavelmente, ao princípio da suficiência. 4. Concluindo a Corte Estadual pela necessidade do réu iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, à luz de motivação excludente, em natureza, das condições da pena restritiva de direito, também recusa a substituição da pena privativa de liberdade, por necessária consequência, ante sua insuficiência. 5. Ordem parcialmente conhecida e denegada" (STJ, HC 31628/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j . 04/09/2007, DJe 04/08/2008) - destaque nosso.

Deverá o réu WASHINGTON, nos termos do artigo 2º, §1º da Lei n.º 8.072/90, com a redação dada pela Lei n.º 11.654/07, iniciar o cumprimento da pena de reclusão no regime fechado, que é o mais adequado diante da gravidade do delito, assemelhado a hediondo, mormente porque não cumprida cautelarmente fração de pena que justifique a fixação de regime mais brando, a teor do que dispõe o artigo 387, §2º do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, a necessidade no particular de fixação do regime mais gravoso em desfavor de WASHINGTON encontra-se fundada no artigo 33, § 3º, do Código Penal e no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006 em função da gravidade concreta do delito, consubstanciada pela flagrante periculosidade do réu, que vem se dedicando ao tráfico e ao roubo desde a adolescência (fls. 36).

Nessa esteira, confira-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: "(...) Para a imposição de regime prisional mais gravoso do que a pena comporta, é necessário fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos. Inteligência das Súmulas n. 440/STJ e 718 e 719 do STF. - Observa-se que, apesar da primariedade do paciente e de o montante da pena (5 anos de reclusão) comportarem, em princípio, o regime inicial semiaberto, a necessidade do regime mais gravoso encontra-se lastreada no art. 33, § 3º, do Código Penal e no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, ante a gravidade concreta do delito, evidenciada pela eleva da quantidade dos entorpecentes apreendidos, elemento que, inclusive, foi valorado na terceira etapa da dosimetria da pena, quando do não reconhecimento do privilégio. Precedentes. - Habeas corpus não conhecido .(HC 416.189/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 07/12/2017).

DISPOSITIVO

Posto isto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, DECLARO WASHINGTON LUIZ MOREIRA CRISPIM, PAULO RICARDO GONÇALVES DOS SANTOS e RAFAEL MOREIRA DIONISIO como incurso no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei n.º 11.343/06. Em consequência, condeno o

réu WASHINGTON LUIZ MOREIRA CRISPIM às penas de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 740 dias-multa, no menor valor unitário, bem como os réus PAULO RICARDO GONÇALVES DOS SANTOS e RAFAEL MOREIRA DIONISIO às penas de 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 266 dias-multa, fixados no menor valor unitário.

Substituo a pena privativa aplicada aos réus PAULO RICARDO GONÇALVES DOS SANTOS e RAFAEL MOREIRA DIONISIO por duas penas restritivas de direito, quais sejam, a prestação de serviços à comunidade, que serão especificados pelo juízo da execução, e a prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo em favor de entidades assistenciais, recaindo, preferencialmente, em favor daquelas voltadas à reabilitação de dependentes químicos.

Pelas razões acima expostas, incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos em favor do réu WASHINGTON LUIZ MOREIRA CRISPIM.

Tendo em vista o regime de pena aplicado e substituição da pena corporal, revogo a prisão preventiva dos PAULO RICARDO GONÇALVES DOS SANTOS e RAFAEL MOREIRA DIONISIO, facultando-lhes o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor dos réus PAULO RICARDO GONÇALVES DOS SANTOS e RAFAEL MOREIRA DIONISIO.

Nego ao réu WASHINGTON LUIZ MOREIRA CRISPIM o direito de recorrer em liberdade, uma vez que os pressupostos da prisão preventiva encontraram-se reforçados com a superveniência da presente condenação. Recomende-se o réu no presídio em que se encontra.

Autorizo a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, guardando-se pequena quantidade para eventual exame futuro, com a ressalva de que, com o advento da Lei nº 11.343/06, deverá ser observado o artigo 32, §2º, que exige a presença do Ministério Público, bem como de autoridade sanitária competente no local da incineração, elaborando-se, ainda, auto circunstanciado e perícia.

Declaro, após o trânsito em julgado, a teor do disposto no artigo 91, inciso II, "b" do Código Penal e no artigo 62 da lei 11.343/06, o perdimento, em favor da União, da importância em dinheiro apreendida em poder dos réus, porque produto do narcotráfico, devendo tal montante ser depositado em conta do Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD, em nome da Secretaria Nacional Antidrogas.

Com o trânsito em julgado: (i) expeça-se guia de execução; (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; (iv) notifique(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de multa; (v) não sendo reclamados eventuais objetos apreendidos, estes serão destinados à leilão/doação, tal como previsto no artigo 123 do Código de Processo penal e artigo 517 das NSCGJ, independente de nova intimação; (vi) se o caso, expeça-se certidão de honorários em favor da patrona nomeada nos autos.

R. Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Caçapava, 07 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA